

1501504-81.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... fls. 68/70... A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que em diligências pelo local observavam o movimento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando viram a acusada em atitude ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501504-81.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001125

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267415/2021 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 20577258 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 213/21/593 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 2267415 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA

Réu Preso

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 16:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Ré: GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC CHRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC LUIZ ANTONIO QUEIROZ - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PC CHRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC LUIZ ANTONIO QUEIROZ, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC LUIZ ANTONIO QUEIROZ, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, a ré GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA foi devidamente interrogada.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 78/80. O processo teve andamento regular. Devidamente notificada, a ré apresentou sua defesa preliminar, sendo a denúncia recebida. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a ré, por fim, interrogada. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, fotografias de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 68/70.. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que em diligências pelo local observavam o movimento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando viram a acusada em atitude suspeita. Realizaram a abordagem e em poder da ré localizaram duas pedras de crack e a quantia de vinte reais em dinheiro. Em buscas pelo monte de folhas que a acusada mexia, localizaram mais 19 pedras de crack, embaladas de forma idêntica às encontradas em poder da acusada. Indagada, a acusada confessou que estava no local realizando a venda de drogas e que o dinheiro que trazia consigo era proveniente de vendas anteriores. No exato mesmo sentido foram as palavras do policial civil Luis Antônio Queiroz, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogada, a ré confessou o crime a si imputado, confirmando que estava vendendo drogas quando foi abordada pelos policiais. Informou que um homem a havia abordado e oferecido drogas - crack - em troca de venda de entorpecentes. Confirmou que havia acabado de vender porções de crack quando foi abordada pelos policiais, tendo confirmado a prática do crime para eles também. Assim, tendo a confissão da acusada sido corroborada pelo restante da prova produzida, tem-se que os fatos descritos na denúncia restaram cabalmente comprovados, sendo a condenação da ré de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que a ré é reincidente (certidão fls. 34), devendo a pena ser agravada na segunda fase. Outrossim, tem-se que a ré confessou o crime, devendo incidir a respectiva confissão. Na terceira fase, ante a reincidência, incabível o redutor no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação da acusada nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, a acusada foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável à denunciada, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Christiano, Policial Civil, declarou que estava passando pelo local dos fatos quando avistou a ré na prática do tráfico de drogas. Efetuaram a abordagem e encontraram porções de crack em poder dela e outras porções em uma mata. Não se recorda se chegaram a flagrar a ré em atividade típica de tráfico de drogas, porém, ela estava na "biqueira" durante a abordagem. Havia outra pessoa no local, que pesquisaram se possuía passagens ou não, mas não se recordam se ele estava comprando drogas da ré. Não lembra se a acusada portava dinheiro. A Promotora solicitou que fosse exibido o depoimento prestado em solo policial. A testemunha, então, leu o seu depoimento e disse que então se recordava de que a ré portava dinheiro e que avistaram a acusada em situação de mercancia. A ré confessou

informalmente o tráfico de drogas. A ré, em interrogatório, declarou que estava em situação de rua quando os fatos ocorreram. Na noite anterior aos fatos, passou a noite toda tentando fazer um programa e obter dinheiro para consumir entorpecentes. Quando o dia amanheceu, estava em estado total de abstinência e um indivíduo se aproximou com uma moto e ofereceu à ré que vendesse algumas porções de crack para ele. Por conta da situação em que estava aceitou e vendeu algumas porções. Logo depois, foi abordada. Excelência, em que pese a acusada ter reconhecido a prática dos fatos, sua confissão, como qualquer outra prova, possui valor relativo e deve ser corroborada pelo restante das evidências dos autos, o que não ocorreu neste caso. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Policiais e da suposta "movimentação suspeita" presenciada, não foram apresentados outros indivíduos na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais dos fatos e/ou como possíveis usuários das substâncias entorpecentes, embora os próprios agentes mencionem que outras pessoas estavam no local. Além disso, verifica-se que o próprio Policial não se recordou efetivamente de diversas circunstâncias da abordagem e somente se lembrou do ocorrido após a leitura de seu depoimento durante a audiência, circunstância que é vedada pelo Código de Processo Penal. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerada reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se

dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminoso), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis à acusada, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (v) seja concedida à acusada a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 11h, na Travessa Amazonas, 1 - Verde, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) pedras de "crack" e 19 porções da mesma droga, totalizando peso líquido de 1,7gs, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, onde iniciaram campana e observaram a acusada, em atitude suspeita, típica de tráfico de drogas. Na ocasião, a ré se dirigia a uma mata, mexia em um monte de folhas e de lá retirava algo e entregava às pessoas com quem mantinha contato, recebendo algo delas em contrapartida. Tal atitude chamou atenção da equipe, que, diante da fundada suspeita, efetuou a abordagem. Em revista pessoal, com a ré foram encontradas duas pedras de "crack" e R\$20,00 em dinheiro. No local em que a ré mexia, foram encontradas outras 19 porções de "crack" idênticas às apreendidas em seu poder, sendo presa em flagrante delito, admitindo para os milicianos, a prática do tráfico.

A ré foi notificada nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 95) e apresentou defesa preliminar (fls. 99/103), seguindo-se a decisão de fls. 104/106, que recebeu a denúncia em 26.11.2021.

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogada a ré.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal da ré.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelas fotografias de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 68/70, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do ato de prisão em flagrante, a ré confessou a prática delitiva. Disse que era usuária de "crack", morava nas ruas e, na data dos fatos, estava realizando a venda de drogas, quando foi abordada pelos policiais. Afirmou que tinha começado a vender drogas naquele local no dia anterior aos fatos. Disse que recebia um kit contendo 24 pedras de "crack" e, depois de vender toda a droga, recebia quatro pedras de "crack" como forma de pagamento. O valor restante era entregue ao "patrão". Aduziu que não desejava informar o nome da pessoa que lhe fornecia as drogas, porquanto temia por sua vida. Alegou que estava arrependida e que somente estava vendendo drogas para sustentar o próprio vício (fls. 04).

Em juízo, ratificou sua versão. Afirmou que estava morando nas ruas e, no do dos fatos, tinha passado a noite toda no local, tentando fazer programa para poder usar drogas, mas não conseguiu. Alegou que, quando o dia amanheceu, estava em estado total de abstinência. Disse que um homem a chamou e correu até ele porque achou que ele queria fazer um programa. Então, ele lhe ofereceu vender drogas para receber algumas porções em troca para seu uso. Afirmou que aceitou e, quando os policiais passaram, tinha acabado de vender quatro porções.

E a confissão foi corroborada pela prova acusatória.

O policial civil Christiano relatou que estavam passando pela Travessa mencionada na denúncia quando avistaram a ré em atitudes suspeitas. Disse que a abordaram e, com ela, encontraram duas porções de entorpecentes e, no pé da árvore perto de onde ela estava, mais porções da mesma droga. Aduziu que, indagada, a ré confessou a prática do crime, dizendo que vinha traficando em razão das dificuldades financeiras que apresentava.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Luís Antônio.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem flagrado a ré em atitudes típicas de tráfico, vindo a apreender duas pedras de "crack" e dinheiro em poder dela, além de 19 porções da mesma droga, embaladas de maneira idêntica às encontradas na sua posse, no local que ela acessava, conduz à certeza quanto à autoria e à traficância.

A quantidade dos entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, às circunstâncias da apreensão e à confissão quanto à traficância, deixam evidente que a droga se destinava mesmo ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de a acusada ser usuária de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Logo, de rigor a condenação da ré, nos termos da denúncia.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que a ré é

reincidente (fls. 82/83). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, anoto que a ré é reincidente (autos 0016763-64.2019 da 2ª Vara Criminal local – cf. certidão de fls. 82/83). De outra banda, confessou a prática do delito. Logo, reputando equivalentes as circunstâncias agravante e atenuante, mantenho a pena base fixada.

Inexistem causas de aumento. De outro lado, a ré não faz jus à redução da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser a ré reincidente e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré GILVIA DANIELE SILVA DE MOURA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se a ré no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário”.

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pela RÉ e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

2) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE.

3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

4) Sai a ré intimada na audiência realizada nesta data, 08/02/2022, para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R\$18.916,81, equivalente a 591,71 UFESPs nos termos do Art. 50 do Código Penal e Art.479, caput, NSCGJ, sob pena de execução do débito a ser ajuizada pelo Ministério Público.

5) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

6) Oportunamente, archive-se.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]